

1500248-44.2021.8.26.0069

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Arthur Lutiheri Baptista Nespoli

Comarca: Bastos

Foro: Foro de Bastos

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... no sentido de que a consumação dos delitos de furto e roubo dispensam a posse mansa, pacífica e desvigiado do bem subtraído, nos termos do verbete nº 582 da súmula da jurisprudência do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bastos

Foro de Bastos

Vara Única

Rua 15 de Novembro nº 50, Bastos-SP - cep 17690-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500248-44.2021.8.26.0069 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500248-44.2021.8.26.0069

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2131329/2021 - DEL.POL.BASTOS, 17908779 - DEL.POL.BASTOS, 296/21/401 - DEL.POL.BASTOS, 2131329 - DEL.POL.BASTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ ANTONIO VIEIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Arthur Lutiheri Baptista Nespoli

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA e ELISÂNGELA ANDRADE CARDOSO, como incursos no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque no dia 14 de maio de 2021, por volta de 0h58, no estabelecimento comercial "Helk Doces e Salgados LTDA", localizado na Rua Ademar de Barros, nº 162, Centro, nesta cidade e Comarca de Bastos, os acusados agindo em concurso e unidade de desígnios, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para proveito comum, durante o repouso noturno, 02 (dois) pacotes de pães caseiros, 02 (dois) pacotes de embalagens, 01 (uma) garrafa de refrigerante, 02 (dois) pacotes de balas "Halls", 01 (um) recipiente contendo álcool em gel e 01 (um) pacote de guardanapo, avaliados globalmente em R\$ 74,00 (setenta e quatro reais - auto de avaliação as fls. 91/93), além da quantia de R\$ 64,60 (sessenta e dois reais e sessenta centavos) em dinheiro, pertencentes à vítima Rafael Hideo

Nakamura.

Apurou-se que, na data dos fatos, os denunciados, previamente ajustados, durante o repouso noturno, dirigiram-se até o estabelecimento comercial de propriedade da vítima, onde ingressaram após arrombarem a janela lateral. Em seguida, subtraíram os diversos gêneros alimentícios e os valores anteriormente referidos, os quais foram colocados no interior de uma sacola. Enquanto José Antônio ficou na posse da sacola, a denunciada Elisângela obteve a posse da quantia de R\$ 22,60, ambos deixando o local.

No entanto, a polícia militar foi acionada e se dirigiram até o comércio, logrando abordar o denunciado José Antônio ainda na posse da res furtiva, cuja sacola ele dispensou ao visualizar a aproximação da viatura policial.

Nesse instante, o denunciado confessou a subtração, bem como afirmou ter cometido o crime juntamente com Elisângela, cujo endereço residencial indicou aos policiais. Os policiais, então, foram até o local indicado e encontraram a denunciada Elisângela na posse da quantia de R\$ 22,60, anteriormente subtraída.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01/02).

Boletim de ocorrência (fls. 10/13).

Auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 14/15).

Fotografias (fls. 42/46).

Na audiência de custódia realizada no dia 14 de maio de 2021 (fls. 79/82), foi concedida a liberdade provisória aos acusados com imposição de medidas cautelares.

Auto de avaliação (fls. 91/93).

Relatório final (fls. 94/97).

Laudo pericial do local (fls. 113/120).

A denúncia foi recebida em 26 de maio de 2021 (fls. 121)

A decisão de fls. 127/129 decretou a prisão preventiva de Elisângela, pois a mesma descumpriu a medida cautelar imposta, reiterou em delito de furto.

A ré Elisângela foi citada (fls. 159), apresentando resposta escrita à acusação (fls. 214/217), sem incursões no mérito.

O réu José foi citado (fls. 161), apresentando resposta escrita à acusação (fls. 200/201), sem incursões no mérito.

Audiência de instrução realizada em 31 de janeiro de 2022, ocasião em que foram ouvidas a vítima e uma testemunha, bem como ocorreu o interrogatório dos acusados (fls. 288/289).

O Ministério Público, em alegações finais orais, pugnou pela procedência da pretensão punitiva com a condenação dos acusados, nos termos da denúncia.

A Defesa da ré Elisângela, em memoriais escritos, pugnou pela absolvição da denunciada, na forma do artigo 386, III, do CPP, em face da incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para furto simples, conforme artigo 155, "caput", reconhecimento do furto privilegiado, vez que o bem furtado é de pequeno valor, por força da norma do artigo 155, § 2º, CP, que a denunciada seja beneficiada com a atenuante da confissão. Requereu ainda a fixação de pena no regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 303/307).

A Defesa do réu José Antonio, em memoriais escritos, pugnou pela desclassificação do delito consumado para o tentado, conforme artigo 14, inciso II, do CP. Seja afastado a causa de aumento de repouso noturno, que o denunciado seja beneficiado com a atenuante da confissão. Requereu ainda a fixação de pena no mínimo legal e regime inicial aberto (fls. 308/311).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

Ao cabo da instrução criminal restou comprovada a responsabilidade do acusado pela prática dos fatos que lhe foram imputados na denúncia.

A materialidade delitiva restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 10/13), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 14/15), fotografias (fls. 42/46), auto de avaliação (fls. 91/93), relatório final (fls. 94/97), laudo pericial do local (fls. 113/120), bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria é certa e recai sobre os acusados.

A vítima Rafael Hideo Nakamura, em juízo, ratificando o que disse em sede inquisitiva (fls. 05), disse que os autores ingressaram ao estabelecimento arrombando a janela lateral e furtaram comidas, bebidas e um valor em dinheiro. Afirmou apenas teve prejuízo da janela danificada que o conserto ficou em torno de R\$ 200,00 (duzentos reais), pois os bens furtados foram recuperados. Aduziu que o horário do furto foi entre 00h e 01h. Relatou que sua esposa ficou traumatizada pelo acontecido. Narrou que conhecia os acusados de vista. Aduziu que reside aos fundos do estabelecimento e ouviu barulhos que vinham do seu comércio, quando percebeu que indivíduos haviam adentrado no local; verificou que havia entrado duas pessoas dentro da cozinha e uma pessoa teria ficado do lado de fora, pedindo que saíssem logo. Alegou que ao ouvir o barulho, ligou imediatamente para a polícia, que rapidamente chegou e prendeu os autores.

A testemunha Sidnei Aparecido Morini, em juízo, ratificando o que disse em sede inquisitiva (fls. 03), aduziu que foram acionados para atender ocorrência de andamento de furto em estabelecimento comercial, na área central da cidade. Relatou que chegando ao local, avistaram um indivíduo, o qual, percebendo a chegada da viatura, dispensou uma sacola ao solo e saiu em fuga, sendo detido logo adiante. Disse que o acusado admitiu que havia ingressado na lanchonete, mediante arrombamento da janela, de onde havia furtado gêneros alimentícios e dinheiro. Afirmou ainda o acusado que estava acompanhado de seus conhecidos Elisângela e Gabriel, indicando onde moravam. Narrou que foram até a residência, que fica localizada a cinco quadras do local do crime, e encontram os dois, sendo todos conduzidos à Delegacia. Declarou que foi encontrada a quantia de R\$ 22,60 em poder de Elisângela. Contou que ambos são conhecidos nos meios policiais por prática de furtos e outros delitos.

O acusado José Antonio Vieira, em sede inquisitiva (fls. 06), afirmou que estava em sua casa, dormindo, quando sua amiga Elisângela chegou dizendo que estava com fome. Aduziu que passaram a procurar por algum local e não encontraram, assim, resolveram adentrar a uma lanchonete para furtar algo para comer. Alegou que arrombou a janela do estabelecimento e, juntamente com Elisângela adentrou ao local, de onde subtraiu dinheiro e gêneros alimentícios. Contou que quando já estava na rua, percebeu a chegada de policiais, e então deixou a sacola que estava carregando e tentou fugir, mas foi preso. O declarante admitiu aos policiais a prática do crime e indicou, preliminarmente, Elisângela e Gabriel como seus cúmplices, entretanto, apenas Elisângela foi com o interrogando. Esclareceu que quando estavam sendo transportados na viatura, a ré lhe desferiu um chute no rosto. Relatou que está arrependido de seu ato. Em juízo, confessou os fatos. Disse que havia feito uso de bebidas alcoólicas no dia dos fatos e passando pelo local Elisângela disse que estava com fome, por essa razão adentram ao local e realizaram o furto. Aduziu que entraram no estabelecimento mediante arrombamento da janela. Relatou que o horário do furto foi 01h da madrugada. Narrou que já foi usuário de entorpecentes, mas atualmente só faz uso de bebidas alcoólicas.

A acusada Elisângela Andrade Cardoso, em sede inquisitiva (fls. 08), aduziu que estava com seu conhecido José andando pela cidade, quando ele decidiu entrar numa lanchonete e subtrair alguma coisa para comerem. Afirmou que só entrou no corredor da lanchonete mas não chegou a subtrair nada. Contou que foi embora e quando estava na frente da sua casa, foi abordada pelos policiais. Esclareceu que com relação ao dinheiro que estava em seu poder afirmou ser seu. Em juízo, disse que no dia dos fatos estava com fome e iria em uma pizzaria porém chegando ao local estava fechada, então desceram na rua do estabelecimento. Relatou que, quando percebeu, José havia arrombado a janela do comércio, e a declarante também entrou na lanchonete. Afirmou que o acusado lhe passou vinte e dois reais e saiu do local, ficando escondida no posto de gasolina. Aduziu que a polícia capturou o acusado na esquina de um mercado, e que Gabriel não tem envolvimento no delito. Narrou que o horário era aproximadamente 00:30h.

Analisando o conjunto probatório, restou evidenciado que os acusados praticaram o crime a eles imputado na exordial acusatória (artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal).

Consoante se depreende dos autos, por meio da narração da vítima, do depoimento da testemunha e do relato dos próprios acusados, fora cometido o furto no estabelecimento comercial "Helk Doces e Salgados LTDA", durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo e mediante concurso de duas pessoas, no qual foram subtraídos diversos objetos descritos na exordial.

O acusado José Antonio confessou, tanto em sede inquisitiva quanto em juízo, que arrombou a janela do estabelecimento, tendo, em seguida, furtado dinheiro e gêneros alimentícios. A acusada Elisângela também confessou, aduzindo que adentrou a lanchonete, tendo sido encontrado em sua posse a quantia de R\$ 22,60 (vinte e dois reais e sessenta centavos).

Conforme já se decidiu: "a confissão, já chamada rainha das provas, é peça valiosa na formação do convencimento judicial. Toda vez que surgir de maneira espontânea, traduzindo a assunção da responsabilidade e afastada a mais remota hipótese de auto imputação falsa, constitui elemento valioso para justificar a condenação" (RJDTACRIM 40/221).

Cabe aqui mencionar que a confissão dos acusados coaduna-se com a declaração da vítima e o depoimento da testemunha.

Ressalte-se que não há qualquer prova, mínima que seja, de que a testemunha ou a vítima tivessem interesse em prejudicar os acusados.

Destaco que, para efeito probatório, o depoimento policial colhido em Juízo deve ser considerado sem reservas, pois que há muito se encontra superada a tese de que as suas palavras não merecem credibilidade sob o mero pretexto da natureza da função que exercem. Ademais, como qualquer outra testemunha ouvida em juízo, está sob a guarida legal e pode incorrer em crime de falso testemunho.

Nesse sentido ainda:

"Como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição de depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo apenas por se tratar de policial (RT 737/606)."

"Prova Testemunha Depoimento de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório Idoneidade. É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (RT771/566)."

Para além da confissão dos acusados e do testemunho policial, a vítima, em juízo, disse que, no dia dos fatos, por volta da 00h e 01h ouviu barulhos que vinham do seu comércio, quando percebeu que indivíduos haviam adentrado no local. Percebeu que havia entrado duas pessoas na cozinha e uma pessoa teria ficado do lado de fora. Disse que os autores ingressaram ao estabelecimento arrombando a janela lateral e furtaram comidas, bebidas e um valor em dinheiro.

A majorante do repouso noturno restou comprovada, ante a confissão dos acusados, a declaração da vítima, e o depoimento da testemunha, todos confirmando que o delito ocorreu entre 00h e 01h.

A qualificadora do rompimento de obstáculo restou devidamente caracterizada, além da declaração da vítima e confissão dos acusados, pelo laudo pericial do local dos fatos (fls. 113/120), no qual consta que: "(...) O acesso ao interior do prédio se deu através da janela da cozinha, a qual possuía duas folhas móveis e duas fixas, de caixilhos metálicos envidraçados, voltada para o terreno vazio, guarnecida por grade metálica externa fixada nas folhas fixas e por tela mosquiteiro, e apresentava-se com a grade e a tela arrombadas mediante uso de instrumento rijo, a guisa de impacto e alavanca, onde se via a torção do quadro da tela e a remoção da grade."

Com relação à qualificadora consistente no concurso de agentes, devidamente caracterizada, pela confissão dos acusados, pelos depoimentos da vítima e testemunha. Inegavelmente, os réus atuaram em conjunto e com unidade de desígnios, visando a subtração dos bens descritos na exordial.

Assim decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça que "caracteriza-se o concurso de

agentes quando há concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, sendo prescindível a identificação do co-réu" (STJ; HC 108.289; Proc. 2008/0126931-1; DF; Sexta Turma Rel. Min. Paulo Benjamin Fragoso Gallotti; Julg. 28/10/2008; DJE 17/11/2008).

Por outro lado, não há que se falar ainda sobre o Princípio da Insignificância. É de se afastar, pois, a figura da insignificância, ante o desvalor da ação dos acusados, causadora de intranquilidade para a população pacata desta cidade, que não suporta mais viver com tamanha sensação de insegurança, provocada por reiterados furtos e cada vez mais corriqueiros nesta urbe, de forma que o eventual reconhecimento da insignificância apenas fomentaria novas práticas delitivas. Não se pode descurar, tampouco, que os acusados possuem envolvimento em crimes de natureza patrimonial, conforme folha de antecedentes criminais (José - fls. 166/182 - Elisângela - fls. 183/190) e certidão de distribuição criminal (fls. José - fls. 312 - Elisângela - fls. 322/326), o que denota a habitualidade delitiva. Aliás, é certo que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento segundo o qual seriam requisitos para o reconhecimento da insignificância os seguintes: (a) ausência de periculosidade social da ação, (b) a mínima ofensividade da conduta do agente isto é: mínima idoneidade ofensiva da conduta, (c) a inexpressividade da lesão jurídica causada e (d) a falta de reprovabilidade da conduta" (HC 84.412-SP, rel. Min. Celso de Mello).

Assim sendo, os réus não fazem jus ao benefício. Aceitar tal conduta seria abrir precedentes ao acaso para que qualquer criminoso na necessidade de obter para si vantagem usasse tais meios para obtenção de lucro em detrimento do trabalho honesto e legalmente permitido em nossa sociedade. Por fim e não menos necessário, as condutas são altamente reprováveis nesta urbe; e não só nesta localidade, mas em nosso país.

Obtempere-se, ademais, que, embora seja fato notório que a Doutrina e a Jurisprudência admitam a figura da insignificância, não menos verdade é que as peculiaridades do caso concreto devam ser levadas em conta pelo julgador a fim de avaliar a situação fática com vistas à aplicação, ou não, de referida figura ao contexto reclamado.

No presente caso, trata-se de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, concurso de agentes e majorado pelo repouso noturno: trata-se de delito concretamente grave. Verifica-se, assim, que o valor da res não é o único elemento para se aferir a causa supralegal. Não se pode afirmar ser mínima a ofensividade da conduta perpetrada, tampouco reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento de agente, que ingressa em estabelecimentos ou fábricas, a fim de subtrair bens, mediante rompimento de obstáculo, concurso de pessoas e durante o repouso noturno, denotando ousadia e temeridade, circunstância incompatível com o combatido postulado.

Nesse sentido, confira-se precisa lição do Ilustre Desembargador CARLOS BUENO: "(...) imagine-se o Poder Judiciário decidir que bens até determinado e pequeno valor podem ser levados por pessoas interessadas, pois isso não caracteriza crime nenhum. Seria o verdadeiro caos, sem dúvida, dispensando-se acréscimo ou ilustração, sempre com a devida vênia. O que se deve levar em contato, é óbvio, é que no apenamento dispensa-se qualquer rigor, agora sim vindo à tona a insignificância da coisa furtada. Ao invés de pena corporal, por exemplo, uma pecuniária, quando possível" (Apel.0000012-48.2012.8.26.0663, 10ª Câmara de Direito Criminal, j. 06/12/2012).

Pelos mesmos motivos acima expostos, resta afastada a figura do privilégio.

No mais, em que pese a alegação da Defesa de José para classificação para modalidade tentada, resta claro que o crime é consumado.

A Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a consumação dos delitos de furto e roubo dispensam a posse mansa, pacífica e desvigiado do bem subtraído, nos termos do verbete nº 582 da súmula da jurisprudência do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Nesse passo, de rigor a condenação dos acusados como incurso no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Passo, pois, à fixação da pena.

Procederei à dosimetria conjunta das penas dos acusados.

A culpabilidade, entendida como o juízo de reprovabilidade da conduta dos agentes, é elevada. Verifico que incidem no caso duas qualificadoras (rompimento de obstáculo e concurso de pessoas); impõe-se, na espécie, o recrudesimento da pena nesta primeira fase, pois a presença de duas qualificadoras denota que o crime praticado é mais grave e a pena não pode ser a mesma que seria aplicada a crime de furto em que incide apenas uma qualificadora. Assim, uma qualificadora deve ser utilizada para tipificar o delito como qualificado, ao passo que a outra, como circunstância judicial desfavorável.

A esse respeito:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, havendo pluralidade de qualificadoras, possível que uma seja utilizada para caracterizar o tipo qualificado e a outra como circunstância judicial desfavorável. 2. No caso, incidiam as qualificadoras do abuso de confiança e do concurso de agentes, sendo que uma serviu para a tipificação do crime de furto qualificado e a outra como circunstância judicial desfavorável - motivo pelo qual a pena-base foi fixada acima do mínimo legal -, não havendo qualquer constrangimento ilegal ocasionado ao paciente. 3. Ordem denegada (STJ, HC nº 202.035/SP, Relator Ministro Og Fernandes, DJe de 15/6/2011). (negritou-se).

O acusado José ostenta péssimos antecedentes, consoante se verifica na certidão de fls. 312/321 (autos de nº 0000611-33.2006.8.26.0069 - condenação pelo artigo 155, §4º, inciso IV, do CP - fls. 312/313); (autos de nº 0001047-89.2006.8.26.0069 - condenação pelo artigo 129, § 1º, inciso II, do CP - fls. 314/315); (autos de nº 0001496-08.2010.8.26.0069 - condenação pelo artigo 155, § 4º, incisos II, IV, do CP - fls. 316); (autos de nº 0002043-87.2006.8.26.0069 - condenação pelo artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV, do CP - fls. 318/319).

Verifica-se, portanto, pela certidão de fls. 312/321, que mesmo já pesando contra si diversas condenações transitadas em julgado, insistiu em permanecer na seara delitiva. Percebe-se facilmente que os mecanismos de repressão criminal não se mostraram suficientes a demover o acusado do estilo de vida marginal. Essa circunstância deve ser atentamente sopesada, ensejando o recrudesimento severo da pena, tudo a prestigiar seu caráter pedagógico, dissuasivo e punitivo.

A acusada Elisângela ostenta maus antecedentes, consoante se verifica na certidão de fls. 322/326 (autos de nº 0000611-33.2006.8.26.0069 - condenação pelo artigo 155, § 4º, inciso IV, do CP - fls. 323); (autos de nº 0001496-08.2010.8.26.0069 - condenação pelo artigo 155, § 4º, inciso II e IV, do CP - fls. 323/324).

Conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, "a condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise justifica o reconhecimento dos maus antecedentes" (HC 281662 RS 2013/0370156-0; Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA; Publicação: DJe 03/04/2014; Julgamento: 27 de março de 2014; Relator: Ministra LAURITA VAZ).

Pelo exposto, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa para José; e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa para Elisângela;

Na segunda fase, referente ao réu José, imperioso o reconhecimento da circunstância agravante da multirreincidência e reincidência específica, conforme certidão de fls. 312/321 (autos de nº 0000978-81.2011.8.26.0069 - condenação pelo artigo 155, § 4º, inciso II, c/c artigo 14 "caput", II ambos do CP - fls. 313/314); (autos de nº 0001935-82.2011.8.26.0069 - condenação pelo artigo 155, "caput", c/c art. 14, inciso II, ambos do CP - fls. 317/318); (autos de nº 0002088-52.2010.8.26.0069 - condenação pelo artigo 155, § 4º, inciso IV, do CP - fls. 319), atestando condenações criminais transitadas em julgado. Presentes também a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP, uma vez que os acusados, em juízo, confessou espontaneamente o crime.

Todavia, tem-se que, por expressa previsão legal, nos termos do artigo 67 do Código Penal (“No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”), a reincidência é preponderante.

Nesse sentido, a jurisprudência dos nossos tribunais, consoante se verificados seguintes arestos, in verbis:

“PENA - Fixação - Atenuantes - Estelionato - Reincidência - Pretensão de abrandamento da pena, ante a confissão - Descabimento - A reincidência é preponderante sobre a confissão - Precedentes do STF - Recurso improvido”. (Apelação Criminal n. 484.465-3/3-00 - Marília - 5ª Câmara Criminal - Relator: Damião Cogan - 28.09.2006 - V.U. Voto n. 9.174);

PENAL. DOSIMETRIA. CONCURSO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. ART. 67, CP. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 1. A teor do disposto no art. 67 do Código Penal, a circunstância agravante da reincidência, como preponderante, prevalece sobre a confissão. Precedentes. 2. Ordem denegada. (HC96061 / MS - MATO GROSSO DO SUL HABEAS CORPUS Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI Julgamento:19/03/2013, Órgão Julgador: Segunda Turma). (negritou-se).

Apelação criminal - (...) Dosimetria (...) Na segunda fase, as reprimendas foram exasperadas em 1/6, em decorrência da circunstância da agravante da reincidência, que deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea (art. 67, do CP). (...). (TJSP; Apelação nº 1501634-55.2019.8.26.530; Juízo de origem: 5ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto; Rel. ELY AMIOKA; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; j. 09.11.2020). (negritou-se).

Sobre a majoração pela reincidência: “Para a justa individualização da pena, na fixação do aumento em face da ocorrência da agravante da reincidência, há que se levar em consideração a natureza do crime anteriormente cometido” (TACRIM SP Ac. Rel. Exmo. Dr. Samuel Júnior - RJD 19/139). “Em se tratando de fixação da pena, a agravação desta pela reincidência, por não estar legalmente limitada, fica a critério do juiz diante do fato concreto” (TACRIM-SP AC Rel. Exmo. Dr. Márcio Bártoli RJS 19/136). No caso concreto, de se pontuar que o réu não reage positivamente aos mecanismos de prevenção, repressão e ressocialização, que, em tese, seriam aptos a demovê-lo do impulso criminoso.

Ainda, mutatis mutandis: “(...) Justamente por isso, já se decidiu que, “[...] apesar de não estabelecida pela norma penal a quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo percentual mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6. Entretanto, é admitida como razoável a adoção de percentual superior mediante fundamentação concreta (multirreincidência, reincidência específica). 3. Não há desproporcionalidade na exasperação da pena do paciente em 1/3, pois a instância antecedente destacou sua reincidência específica” (STJ, HC 331534/SP, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 27-10-2015, grifei). “2. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o magistrado destaca que o paciente é reincidente específico, fato que justifica o incremento da pena, em 1/3 (um terço), na segunda fase da dosimetria” (STJ, HC 294143/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, sem grifo no original). “Hipótese em que a fração de 1/3, utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, lastreou-se no fato de ser o paciente reincidente específico, argumento que se alinha à jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes” (STJ, HC348170/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado 26-4-2016, grifei). Precedente da mais alta Corte deve ser lembrado: “A reincidência específica é agravante que sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do crime” (STF, HC 101918/MS, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 04-06-2010, grifei). (...)” (Apelação nº 0011365-86.2009.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, Colenda 15ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, Exmo. Des. JULIO CAIO FARTO SALLES, julg., em 16 de março de 2017).

Por conseguinte, se o réu ostenta reincidência, enseja a exasperação em 1/6; em

sendo específica, oportuniza incremento mais rigoroso, qual seja, 1/3 (um terço). Se para além da reincidência específica, o acusado é multirreincidente, a pena deve ser agravada em 1/2 (metade).

Nesse passo, em função da prevalência da reincidência específica e da multirreincidência, mas sem desconsiderar a confissão, majoro a pena anteriormente fixada no importe mais brando de 1/3 (um terço) e fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa para José.

A pena de Elisângela sofre alteração nesta fase, pois presente a atenuante da confissão, razão pela qual minoro a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, presente a causa de aumento prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal (repouso noturno), razão pela qual majoro a pena anteriormente fixada em 1/3 (um terço), resultando na reprimenda de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa para o réu José; e 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezesete) dias-multa para a ré Elisângela.

Ausentes demais causas modificadoras da pena, torno a reprimenda acima definitiva. Considerada a situação econômica dos acusados, que ao que consta não goza de padrão de vida elevado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente desde então.

Fixo o regime prisional inicial fechado para o acusado José, nos moldes do artigo 33 do CP, considerando a quantidade de pena imposta, os péssimos antecedentes e a multirreincidência específica. Regime inicial menos gravoso mostrar-se-ia insuficiente para reprovação e prevenção do crime. Verifica-se, pelas extensas certidões de feitos criminais do acusado (fls. 312/321), que mesmo já pesando contra si diversas condenações ou processos criminais pendentes, insistiu em permanecer na seara delitiva. Percebe-se facilmente que os mecanismos de repressão criminal não se mostraram suficientes a demover o acusado do estilo de vida marginal, continuando a fazer do desfalque ao patrimônio alheio seu modo de subsistência. O imputado ostenta diversos envolvimento com delitos contra o patrimônio (furto), vários relativos a condutas recentes praticadas nos últimos anos. Ou seja, o imputado insiste em permanecer na seara criminosa, razão pela qual a resposta punitiva estatal deve ser rigorosa, tudo a se fazer eficiente seu caráter dissuasivo-pedagógico, a se demover o acusado da recidiva delitiva. Não se pode descuidar da gravidade concreta do fato, pois que incidentes duas qualificadoras, para além de ter sido cometido durante o repouso noturno.

Inaplicáveis as benesses dos arts. 44 e 77 do CP pelos mesmos motivos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena de Elisângela, verifica-se que, analisando o montante de pena aplicado, maus antecedentes e as circunstâncias judiciais negativas de rigor a aplicação do regime semiaberto. Verifica-se pela certidão de antecedentes da acusada (fls. 322/326), que pesam contra a ré diversos envolvimento com a Justiça Criminal. Percebe-se facilmente que os mecanismos de repressão criminal não se mostraram suficientes a demover a acusada do estilo de vida marginal, continuando a fazer do desfalque ao patrimônio alheio seu modo de subsistência. De fato, a imputada ostenta diversos envolvimento com delitos contra o patrimônio (furto). Ou seja, a ré insiste em permanecer na seara criminosa, razão pela qual a resposta punitiva estatal deve ser rigorosa, tudo a se fazer eficiente seu caráter dissuasivo-pedagógico, a se afastar a acusada da recidiva delitiva. Não se pode descuidar tampouco da gravidade concreta do crime praticado, pois que incidente duas qualificadoras, para além de ter sido cometido durante o repouso noturno. Inaplicáveis as benesses dos arts. 44 e 77 do CP pelos mesmos motivos.

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO o réu JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, no mínimo unitário legal, como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código

Penal; e CONDENO a ré ELISÂNGELA ANDRADE CARDOSO, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no mínimo unitário legal, como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal. Faculto aos réus o direito de recorrer em liberdade nestes autos.

Após o trânsito em julgado desta sentença:

1. Notifiquem-se os condenados para o pagamento de multa no prazo de 10 (dez) dias, art. 50, do CP.

2. Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para fins do disposto no art. 15, III, da CF.

3. Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD).

Expeça-se todo o necessário, fazendo as comunicações de praxe, inclusive à vítima. Por fim, condeno os réus ao pagamento da verba a que se refere o artigo 4.º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as comunicações e cautelas de praxe.

P.I.C.

Bastos, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA